

1501177-09.2020.8.26.0006

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Resistência

Magistrado: José Ricardo Santini Antonietto

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... veja-se:EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) As penas restritivas de direitos são, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

1ª Vara Criminal

Rua Dr. João Ribeiro nº 433, Sala 301 - 3º andar, Penha - CEP 03634-010, Fone: (11) 4635-8571, São Paulo-SP - E-mail: penha1cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501177-09.2020.8.26.0006 - Ação Penal - Procedimento Sumário

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3043489/2020 - 65º D.P. ARTUR ALVIM, 11756652 - 65º D.P. ARTUR ALVIM

Réu:

Vinicius Marques dos Santos Malgueliro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

01 de setembro de 2022

Em 01 de setembro de 2022, à hora designada, na sala de audiências do Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal do Foro Regional VI - Penha de França, onde presente se encontrava o MM. Juiz de Direito, Dr. JOSÉ RICARDO SANTINI ANTONIETTO, comigo escrevente ao final assinado, foi aberta a presente audiência de Instrução, Debates e Julgamento. Apregoadas as partes, compareceram o representante do Ministério Público, DR. ADOLFO SAKAMOTO LOPES, e o réu VINICIUS MARQUES DOS SANTOS MALGUEIRO, qualificado nos autos, acompanhado de seu defensor constituído, DR. EMERSON MARTINS, OAB/SP nº 309.450. Iniciados os trabalhos, foi ouvida uma testemunha de defesa, pelo sistema audiovisual, cuja qualificação segue em apartado. Logo após, foi realizado o interrogatório do réu, pelo mesmo sistema, cujo termo de qualificação também segue em apartado. Pelo MM. Juiz foi dito que por não haver mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução e determinava que se passasse aos debates. Pela ordem, foi DADA A PALAVRA AO DR. PROMOTOR e pelo mesmo foi dito que: Trata-se de ação penal movida contra vinicius marques dos santos malgueliro pela prática dos crimes dos artigos 28 da Lei n.º 11343/2006, 129, caput, 329 e 331, todos do Código Penal, e 21 do Decreto-lei n.º 368/41, tudo em concurso material, porque: 1. No dia 05 de junho de 2020, por volta das 09h10, na Rua Padre Gabriel de Campos, altura do nº 500, bairro Artur Alvim, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, 1,2 gramas de

substância contendo tetrahydrocannabinol e 0,1 grama de cocaína, drogas que causam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar nos termos das listas F2 e F1, respectivamente, da Portaria n.º 344/98 SVS-MS, conforme laudo de constatação de fls. 10/13; 2. Nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, desacatou os funcionários públicos Rogério dos Santos Lima e Sideam de Oliveira, no exercício de suas funções; 3. Da mesma forma, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência física contra os policiais Rogério dos Santos Lima e Sideam de Oliveira, funcionários competentes para executá-lo; 4. Também nas mesmas circunstâncias já descritas, ofendeu a integridade corporal de Sideam de Oliveira, provocando-lhe ferimento de natureza leve consistente em escoriação na face dorsal do terceiro quirodáctilo direito, conforme laudo de exame de corpo de delito de fl. 42; 5. Por fim, logo após a prática dos crimes anteriores, no interior do pronto socorro da UPA de Itaquera, praticou vias de fato contra o policial Rogério dos Santos Lima. É dos autos que o denunciado caminhava pela via pública acima mencionada e viu uma viatura policial passar, dentro da qual estavam os policiais militares Rogério dos Santos Lima e Sideam de Oliveira. Ato contínuo, mostrou o dedo médio na direção deles e xingou os dois dizendo “filhos da puta”, desacatando-o os policiais que estavam no exercício de suas funções. Diante da fundada suspeita e caracterizada a situação flagrancial, os policiais realizaram sua abordagem e busca e apreensão pessoal, ocasião em que encontraram dentro de um porta-óculos 1,2 grama de “maconha” e 0,1 grama de cocaína, drogas que ele trazia consigo para consumo pessoal, conforme laudo de constatação de fls. 10/13. Ao ser informado de que seria conduzido a distrito policial, VINICIUS passou a exaltar-se, sendo necessário o uso da força física e, ao tentar evitar não ser algemado, o denunciado opôs-se à execução do ato legal, mediante violência física a desferir chutes e socos nos policiais. Com essa conduta VINICIUS ofendeu a integridade corporal do policial militar Sideam de Oliveira, o qual sofreu escoriação discreta na face dorsal do terceiro quirodáctilo direito, conforme laudo pericial de fl. 42. Sideam ofereceu representação, conforme documento que acompanhou a denúncia (fl. 50). O denunciado foi levado ao pronto socorro da UPA - Itaquera, assim como as vítimas, local onde praticou vias de fato contra o policial Rogério ao novamente desferir chutes. A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2021 (fl. 58), o réu foi citado (fl. 70), apresentou a resposta escrita à acusação de fls. 76/81 e o recebimento da denúncia foi mantido (fl. 83). Em audiência foram colhidos os depoimentos das duas testemunhas arroladas na denúncia, uma arrolada pela defesa e o réu foi interrogado. É o relatório. Preliminarmente anota-se que não foi ofertada nenhuma benesse ao acusado em razão da somatória das penas dos delitos descritos na denúncia e porque dois dos delitos foram cometidos mediante violência contra a pessoa. I. No mérito, o pedido é PROCEDENTE. A materialidade dos delitos é certa e foi comprovada pelos laudos de constatação de fls. 10/13 e químico toxicológico de fls. 55/57, laudo de exame de corpo de delito de fl. 42, bem como pela prova oral colhida sob contraditório. II. A autoria também é certa e recai sobre o acusado. Bem assim, o policial militar Sideam de Oliveira disse: “Estávamos em patrulhamento, ele vinha em sentido oposto. Ele mostrou o dedo da mão para a gente. Voltamos e fizemos a abordagem. Ele não aceitou a abordagem. Ele foi levado ao PS para atendimento médico e depois para a delegacia. Ele estava com um colega, mais uma pessoa. Ele fez o gesto com o dedo de forma gratuita. Ele relatou que já tinha feito isso anteriormente, notadamente em manifestações do centro, contra policiais e contra o Estado. Ele disse que era contra policiais e contra o Estado. As palavras ele disse, mas não me recordo. Houve palavrões também. Ele disse que estava sem dormir, mas não tenho certeza se ele estava sob o efeito de álcool ou droga. Ele estava com odor, cheiro de álcool. Não notei sinal de droga. Não me recordo bem, mas tinha maconha. Não sei se tinha outras drogas. A droga estava em um objeto, um porta óculos que ele levou. Ele disse que era para consumo próprio. Ele ficou exaltado quando dissemos que seria levado ao distrito, reagiu da abordagem, tivemos que tomar as medidas necessárias para conduzi-lo, foi necessário algemá-lo. Eu me machuquei na mão, não me recordo bem. Passei no PS. Eu me machuquei em razão da resistência dele, ele não queria ir para o distrito, então

teve reação. No PS teve nova violência, inclusive contra uma enfermeira. Ele conseguiu atingir meu parceiro, uma voadora, um chute em meu parceiro. Não me recordo se machucou. Não o conhecia anteriormente. O outro rapaz colaborou. Muito difícil falar para o senhor isso, ele já estava à vontade. Ele teve as mesmas atitudes anteriores, então se sentiu à vontade para fazer isso. A gente pesquisa tudo, não me recordo se ele tem mais alguma condução para o distrito policial. Passei no PS e no IML. Mas tem tudo no boletim de ocorrência e no inquérito policial". A testemunha policial militar Rogerio dos Santos Lima relatou: "Estávamos em patrulhamento, ele motivou a abordagem, ele vinha na calçada oposta com um rapaz, xingando e ofendendo a equipe policial, inclusive com dedo. Ele estava transtornado, tivemos que usar a força para algemá-lo e conduzi-lo ao distrito policial. Levamos ao distrito e o delegado solicitou que passássemos pelo PS. Ele tentou desferir chutes em mim. Ele se intitulou como black block. Ele disse que não gostava da polícia, que era oposto ao Estado, que no Centro é mais normal fazer isso aí, e que sempre iria se opor ao Estado e à Polícia. Ele foi abordado porque começou a nos ofender gratuitamente, ele fez gesto obsceno com o dedo médio. O outro garoto que estava com ele não se opôs a nada. Foi encontrada droga em um porta óculos que estava em seu poder, aparentemente era maconha. Não me recordo se tinha cocaína. Ele continuou a agressão ativa contra a equipe e não entendi porque ele fazia isso. Normal ele não estava. Em situação normal nenhum cidadão faria o que ele fez. Provavelmente ele tinha consumido entorpecente e álcool. Meu parceiro se lesionou no braço, algum tipo de arranhão quando tentava fazer a detenção do mesmo. No posto ele estava algemado, mesmo assim ele me chutou e acertou. Não me recordo como meu parceiro foi agredido. Não o conhecia anteriormente. Após fiquei sabendo que residia no bairro. Ele nos xingou, mas não me recordo o que ele teria dito. Não percebi nenhum distúrbio de ordem psicológica. Mas não foi nenhuma atitude normal pela situação que ele proporcionou". A testemunha arrolada pela defesa Dario Alexandre da Silva Souza contou: "Eles não nos revistaram quando nos abordaram. Quando a viatura passou, eles ficaram nos encarando e Vinicius disse: 'o que foi?'. Vinicius estava meio alterado, não queria ser abordado. Houve luta corporal, quebrar o óculos dele. Nos colocaram no camburão. Quando estava na delegacia fui conversar com o delegado e os policiais ficaram com Vinicius. Depois, umas 11 ou meio dia, levaram ele para fazer exame de corpo de delito e quando ele voltou estava todo machucado. Eles disseram que Vinicius tentou agredir eles, mas estavam dando risada. Estava com ele andando pela calçada. Como eles estavam nos encarando, Vinicius não gostou e perguntou o que foi. Eu não vi ele exhibir o dedo do meio. Também não vi ele xingar os policiais. Ele ficou bravo quando começou a ser agredido, já na delegacia. Ele só não queria ser colocado no camburão, mas os policiais levaram a gente. Ele não queria ser algemado e foi nessa hora que nos jogaram no chão. Foi encontrada a droga com ele quando fizeram a revista. Tinha vestígios dentro do saquinho. No dichavador dele tinha maconha. Vestígios de maconha e de cocaína. Eu consumo maconha. Eu não disse nada disso que consta da delegacia. Eu disse para ele que não concordava com o que estava escrito e só assinei porque já eram 4 horas da tarde e eu queria ir embora. Reconheço minha assinatura a fl. 17. Li o depoimento enquanto conversava com o delegado. A gente estava cansado, tínhamos virado a noite. Vinicius tinha consumido droga. Não consumimos junto. Vinicius tinha fumado, bebido bastante e usou cocaína sim. Vinicius estava meio descontrolado por causa da droga. A gente tinha saído de uma festa". Por fim, em autodefesa o réu comentou: "Eu realmente só tenho uns flashes, eu estava muito bêbado. A viatura passou encarando, olhando muito para mim, senti um olhar de julgamento mesmo. Abri os braços para dizer tipo "o que foi?". Eles vieram me abordar, vieram bruscamente para cima de mim, não estavam conseguindo me conter, um veio por trás e me enforcou e o outro me deu uma rasteira. Nisso eu caí no chão e quebrou o meu óculos. Não sei qual policial, mas um deles colocou o joelho no meu pescoço e pensei que ia morrer, porque já vi policial matando desse jeito. Depois conseguiram me algemar e colocaram no camburão. Depois não tenho mais lembrança. Lembro de ter ido ao posto, foi quando o policial disse que eu o agredi. Como eu estava ficando machucado, eu realmente chutei eles. Em nenhum momento os agredi ou os xinguei. Passei 9 horas dentro da delegacia preso. Optei por não fazer

o exame de corpo de delito porque disseram que teriam que tirar fotos e essas fotos poderiam vazarem. A droga era minha, para meu consumo próprio. Não mostrei o dedo do meio para eles". Como se vê, a prova oral comprovou as práticas dos delitos descritos na denúncia. O réu, de fato, trazia consigo droga para seu consumo próprio, haja vista a quantidade de entorpecente. De igual forma, incorreu o réu no crime de lesão corporal contra a vítima Sideam, ao produzir-lhe ferimentos de natureza leve, conforme laudo pericial de fl. 42. Incorreu o acusado, também, no crime de desacato ao se insurgir de forma ativa contra os policiais militares, funcionários públicos competentes para a prática do ato. Da mesma forma, obrou o réu com desrespeito para com a condição de agentes públicos ao xingar os mesmos policiais que estavam no exercício de suas funções. Por fim, ainda não contente, em outro contexto, quando já estava recebendo atendimento médico, desferiu chutes no policial Rogério. Todas as condutas praticadas pelos réus foram cometidas de forma gratuita e sem nenhuma justificativa. Diante desse contexto, mister o reconhecimento dos delitos descritos na denúncia e o desate condenatório. III. No que diz respeito à dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis, não há agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena. As penas deverão ser somadas diante do concurso material de delitos. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão de os crimes terem envolvido violência física contra a pessoa. O regime penitenciário deve ser o inicial aberto. IV. Ante o exposto, requer-se a procedência do pedido para condenar Vinicius Marques dos Santos Malgueiro pela prática dos crimes dos artigos 28 da Lei n.º 11343/2006, 129, caput, 329 e 331, todos do Código Penal, e 21 do Decreto-lei n.º 368/41, tudo em concurso material. Em seguida, foi DADA A PALAVRA AO DR. DEFENSOR e pelo mesmo foi dito que: MM. Juiz, VINÍCIUS MARQUES DOS SANTOS MALGUEIRO, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, através do artigo 44 do Código de Processo Penal, ao qual outorga poderes especiais ao seu procurador ao final subscritos, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos termos do art. 403 § 3º do Código de Processo Penal, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS: Pelas razões de fato e de Direito a seguir expostas. Da Inimputabilidade Penal do Acusado: Nas conformidades do documento em anexo apresentado pela defesa, constata-se que há necessidade da absolvição do acusado tendo em vista os problemas psicológicos apresentados em virtude da doença crônica (borderline) agravada pelo uso constante de entorpecentes. Constata-se que o fato somente ocorreu pelas condições de saúde apresentada pelo réu que naquele dia estava sob efeito de drogas e não sabia o caráter ilícito da sua conduta. O denunciado, possui distúrbio de pânico, Borderline, ansiedade, explosividade e extrema impulsividade, além da apresentação de problemas esquizofrênicos, ficando comprovado por meio de laudo médico e guia de receita de medicamentos para o tratamento contínuo de tais distúrbios. Tanto é que já tentou contra a própria vida pulando de uma ponte, conforme relatório médico em anexo (fls. 101). Em matéria de defesa, faz-se constar a importância do artigo 26 do Código Penal Brasileiro, uma vez que a legislação vigente trata da inimputabilidade penal do acusado por razões por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e como já abordado, o denunciado sofre de problemas mentais que causam a sua inimputabilidade. Vejamos o artigo 26 do Código Penal Brasileiro, Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento."Portanto, no que tange ao direito processual brasileiro, este assegura ao réu isento de pena por razão de inimputabilidade penal, devendo, portanto, ao Magistrado absolver o Réu pelas razões do inciso "VI" do artigo 386 Código de Processo Penal. Observemos: "Código de Processo Penal - Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:" (...) "VI - existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do artigo 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;". Vossa Excelência, por essas razões alegada, evidência em tese e na prática, que o ocorrido se deu principalmente pelo fato do acusado apresentar problemas psicológicos e não entender naquele momento o

caráter ilícito da conduta pelo uso de entorpecentes. Além disso, é incontestável o estado de embriaguez pelo uso de drogas no dia dos fatos, tanto é, que foi encontrado na posse do Réu as substâncias “maconha e Cocaína”. O código penal em seu artigo 28, § 1º e 2º, estabelece que: § 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. § 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Sendo assim, requer a absolvição do acusado por sua inimputabilidade decorrente do estado em que se encontrava na data dos fatos. No tocante ao porte de 1,2 gramas de “maconha” e 0,1 grama de cocaína, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal cuidou do assunto no dia 13 de fevereiro de 2007, ao apreciar o RE 430105/QO/RJ, de que foi relator o Min. Sepúlveda Pertence, e se posicionou, com o seguinte entendimento: “A Turma, resolvendo questão de ordem no sentido de que o art. 28 da Lei 11.343/2006 (Nova Lei de Tóxicos) não implicou abolitio criminis do delito de posse de drogas para consumo pessoal, então previsto no art. 16 da Lei 6.368/76, julgou prejudicado recurso extraordinário em que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro alegava a incompetência dos juizados especiais para processar e julgar conduta capitulada no art. 16 da Lei 6.368/76. Considerou-se que a conduta antes descrita neste artigo continua sendo crime sob a égide da lei nova, tendo ocorrido, isto sim, uma despenalização, cuja característica marcante seria a exclusão de penas privativas de liberdade como sanção principal ou substitutiva da infração penal. Afastou-se, também, o entendimento de parte da doutrina de que o fato, agora, constituir-se-ia infração penal sui generis, pois esta posição acarretaria sérias consequências, tais como a impossibilidade de a conduta ser enquadrada como ato infracional, já que não seria crime nem contravenção penal, e a dificuldade na definição de seu regime jurídico. Ademais, rejeitou-se o argumento de que o art. 1º do DL 3.914/41 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirconferenciadocumento.do>, informe o processo 1501177-09.2020.8.26.0006 e código E5B4FB8. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALVARO BRAZ, protocolado em 28/07/2021 às 15:17, sob o número WPEN21701142970 . fls. 77 (Lei de Introdução ao Código Penal e à Lei de Contravenções Penais) seria óbice a que a novel lei criasse crime sem a imposição de pena de reclusão ou de detenção, uma vez que esse dispositivo apenas estabelece critério para a distinção entre crime e contravenção, o que não impediria que lei ordinária superveniente adotasse outros requisitos gerais de diferenciação ou escolhesse para determinado delito pena diversa da privação ou restrição da liberdade. Aduziu-se, ainda, que, embora os termos da Nova Lei de Tóxicos não sejam inequívocos, não se poderia partir da premissa de mero equívoco na colocação das infrações relativas ao usuário em capítulo chamado 'Dos Crimes e das Penas'. Por outro lado, salientou-se a previsão, como regra geral, do rito processual estabelecido pela Lei 9.099/95. Por fim, tendo em conta que o art. 30 da Lei 11.343/2006 fixou em 2 anos o prazo de prescrição da pretensão punitiva e que já transcorreria tempo superior a esse período, sem qualquer causa interruptiva da prescrição, reconheceu-se a extinção da punibilidade do fato e, em consequência, concluiu-se pela perda de objeto do recurso extraordinário (STF, 1º Turma, RE 430105 QO/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 13.2.2007. Informativo n. 456. Brasília, 12 a 23 de fevereiro de 2007). DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA:

A testemunha Dario informou que o Réu em nenhum momento fez gestos obscenos aos policiais, informou ainda que o Réu apenas se defendeu da truculência usada pela polícia na abordagem, relatou que o Réu havia feito uso de substâncias entorpecentes “maconha, cocaína e Bebidas alcoólicas”. Conforme pode se observar Excelência, não existe nenhuma prova dos crimes alegados pelos policiais, sendo assim, requer a absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação. Dos Possíveis Critérios de Fixação da Pena: Embora nítida a tese da absolvição devida aos problemas psicológicos, além da observância das oitivas que

fica claro que o acusado teve um surto psicótico ao ser abordado pelos policiais. Analisando a situação do denunciado, é possível concluir que este é réu primário e de bons antecedentes, além de possuir residência fixa. Nesse sentido entende o Supremo Tribunal Federal, senão veja-se:EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. (...) Mais uma vez, em caso de condenação, Exmo Senhor Juiz, solicito que o Réu possa ter avaliado e considerado os seus antecedentes, além dos seus comportamentos sociais, como também a personalidade do acusado, para que se possível, seja aplicada a este caso in concreto o inciso "IV" do artigo 59 do Código Penal. Reparemos: Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: IV - a substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. Assim, por meio de Vossa Excelência, ao denunciado deve ser deferida a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que o acusado cumpre todos requisitos para tal benefício. Reconhecimento de Atenuantes: Na ocasião do não acolhimento da tese de absolvição do apelante e desclassificação do tipo penal, imprescindível se torna o reconhecimento das atenuantes em razão da confissão da autoria do crime de forma espontânea à autoridade policial, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, tendo em vista que durante o interrogatório o acusado confessou espontaneamente. No entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a partir do Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, decide pela manutenção da aplicação do artigo 63, inciso "III" do Código Penal. Atenta-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. ALEGAÇÃO DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO. CONFISSÃO QUALIFICADA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.[...] 2. Como é cediço, não se exige motivação às decisões do Conselho de Sentença, que, em última análise, estão baseadas na íntima convicção dos jurados. Dessa forma, não há como o Tribunal local precisar se a confissão do acusado foi ou não determinante para a formação do convencimento dos jurados.3. [...] 4. Ademais, importa ressaltar que a confissão, mesmo que parcial ou qualificada, dará ensejo à referida atenuante. (AgRg no REsp 1.724.006/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018) Além do que já foi posto, há entendimento consolidado nas cortes judiciais nacionais, por meio de súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no enunciado de n.º 545, no que tange a confissão espontânea do denunciado em sede inquisitorial. Destaca-se: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (SÚMULA 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)" Assim, portanto, ao acusado deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, uma vez que, é escassa a sua sanidade mental, uma vez que este sofre de problemas psicológicos graves além de ser usuário de entorpecentes. Que seja revisada a dosimetria da pena conforme garantida pela legislação penal; ainda mais, que sua pena seja imposta no mínimo legal pelas circunstâncias já elencadas. Da

Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Pena Restritiva de Direito: Com o intuito da ressocialização do indivíduo, a Justiça presente deve buscar aplicar o que se enquadra na realidade da nossa sociedade atual. Nos dias de hoje, infelizmente, o Sistema Prisional Brasileiro é rodeado de incertezas sobre a sua verdadeira função de ressocialização por meio da pena mantendo pessoas de bons antecedentes em cárcere, tem-se em vista que as unidades prisionais brasileira no geral são em síntese, uma "escola do crime". Nesse sentido, com o entendimento no princípio da presunção de inocência, com fulcro na Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LVII, requer que seja posto em liberdade o denunciado, até que seja transitado em julgado, visto que as circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado (art. 282, inciso II, CPP) lhe são favoráveis pelo fato de não constar reincidência e sua conduta social não ser em momento algum alvo de questionamento. É importante que, meritíssimo, a substituição da pena privativa de liberdade por qualquer das penas restritivas de direito, assim, previstas no artigo 43 e seguintes do Código Penal. Vejamos: Art. 43. As penas restritivas de direitos são: I - prestação pecuniária; II - perda de bens e valores; III - limitação de fim de semana. IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; V - interdição temporária de direitos; VI - limitação de fim de semana. Portanto, importante trazer à baila o artigo 44 do Código Penal, tendo em vista que o acusado atende os requisitos dos incisos "II" e "III" do artigo supramencionado. Ademais, sabe-se que o denunciado não possui maus antecedentes criminais anteriores a esta ocasião aqui discutida, além da sua personalidade que é uma pessoa com retardos mentais ao qual não tem a mesma capacidade de outros indivíduos que estejam encarcerados em sedes prisionais que o mesmo esteja. De Outras Medidas Cautelares: Vossa Excelência, mister se torna trazer à baila a importância da aplicação de medidas de segurança em caso de condenação do acusado. É imprescindível que o acusado possa desfrutar das condições estabelecidas no artigo 319 inciso "VI" do Código de Processo Penal, sabendo-se que esse é uma pessoa inimputável devido as suas dificuldades acompanhadas de transtornos de pânico (provado em processo), com constantes ataques epiléticos, e ainda, em razão da sua esquizofrenia ofertando a sua completa insanidade mental. Logo, tem-se em vista que o mesmo atende a todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, para que possa assim responder em regime inicial de cumprimento de pena mais brando. Da substituição da Pena Por Medida de Segurança. Além do Código Penal prevê por tal condição positiva para o devido tratamento do apenado, se faz interessante trazer a discussão o artigo 183 da Lei de Execução Penal, ao qual também autoriza quando constatado doença mental ou perturbação da saúde mental, que seja de ofício requerido perante o parquet ou a qualquer outro responsável que seja ordenada a substituição da pena por medida de segurança, para que assim, possa resguardar a saúde mental do acusado. Observemos: "Art. 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança." Enfim, que Vossa Excelência possa apreciar e deferir procedente toda a fundamentação aqui abordada, que, tem por finalidade a busca incansável pelo direito deste acusado ao qual se encontra sendo processo pelo ente estatal punitivo. DOS PEDIDOS: Ante todo exposto, requer a Vossa Excelência digne-se a: Meritíssimo Senhor Juiz, primariamente, requer esta defesa vos subscreve, o acolhimento da defesa para a então Absolvição do acusado em razão da inimputabilidade penal que já foi argumentada nas tenazes do inciso "VI" do artigo 386 do Código de Processo Penal, c/c artigo 26 e 28 do Código Penal; e caso Vossa Excelência entenda que não seja este o entendimento, que seja absolvido por não existir prova suficiente para a condenação, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. ou; subsidiariamente requer a Vossa Excelência, caso do provimento da decisão seja em manter a condenação do proposta pelo parquet, quanto a qualificação do crime, requer-se a Vossa Excelência, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. e/ou; No caso se o Ilustre Magistrado entendeu pela

condenação, solicito-o a aplicação da pena no mínimo necessário, ad argumentum, além da pena seja fixada no mínimo legal e que o denunciado possa responder em

liberdade com regime inicial aberto ou semiaberto, por preencher os requisitos objetivos para tal benefício. Ainda requerendo, que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso "III", alínea d do Código Penal; ou, ainda; Requer, em caso de condenação, a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou por restritiva de direitos, previsto no artigo 43 do Código Penal, visto que preencha todos os requisitos conforme art. 44 do Código Penal; Ora, requer-se, em caso de condenação, que Vossa Excelência conceda a este acusado a possibilidade de este responder em prisão domiciliar como já se tem argumentado; pois tais razões, a defesa incessantemente buscará provar no que for necessário, usando de todos os meios admitidos em direito, em especial pela juntada de documentos (anexos no processo), prova testemunhal, pericial e o depoimento pessoal do acusado e das testemunhas aqui arroladas. Nestes termos, Pede Deferimento. Após, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de ação penal pública movida contra VINÍCIUS MARQUES DOS SANTOS MALGUEIRO, qualificado nos autos, como incurso nos arts. 28 da Lei nº 11.343/06, 129, caput, 329 e 331, todos do Código Penal, e 21 do Decreto-lei nº 3.688/41, tudo na forma do art. 69 do Código Penal. Consta que o réu, no dia 05/06/2020, por volta das 09h10min, na Rua Padre Gabriel de Campos, altura do nº 500, Artur Alvim, nesta Capital, trazia consigo, para consumo pessoal, 1,2 g de maconha e 0,1 g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, desacatou os policiais militares Rogério dos Santos Lima e Sideam de Oliveira, no exercício de suas funções, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência física contra tais policiais, provocando lesões corporais de natureza leve em Sideam e praticando vias de fato contra Rogério. Segundo a denúncia, o réu caminhava pela via pública e viu uma viatura policial passar, na qual se encontravam Rogério e Sideam, tendo mostrado o dedo médio na direção deles e os xingado de "filhos da puta", desacatando-os. Diante disso, foi feita a abordagem e na revista pessoal encontraram dentro de um porta-óculos 1,2 g de maconha e 0,1 g de cocaína, destinadas ao consumo pessoal. Ao ser informado de que seria conduzido à delegacia, o réu exaltou-se e ao tentar evitar ser algemado opôs-se à execução de tal ato mediante violência física, desferindo chutes e socos nos policiais, provocando lesões corporais de natureza leve em Sideam. O réu e Sideam foram levados ao pronto-socorro, onde o réu praticou vias de fato contra Rogério, desferindo-lhe chutes, sem contudo lesioná-lo (fls. 46/48). O réu não fez jus à transação penal, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal, de acordo com a cota ministerial de fls. 49, item 2. A denúncia foi recebida em 15/02/2021 (fls. 58). O réu foi citado (fls. 69/70), sobrevivendo a defesa de fls. 76/81. Afastada a absolvição sumária (fls. 83), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, sendo ouvidas as vítimas e uma testemunha de defesa, interrogando-se a seguir o réu. Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, enquanto a defesa postulou a absolvição do réu. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. Com efeito, a vítima Sideam de Oliveira, policial militar, disse que no dia dos fatos estava a bordo de uma viatura realizando patrulhamento, quando avistou o réu e outro indivíduo caminhando no sentido oposto, tendo o réu, sem motivo algum, mostrado o dedo médio na sua direção e de seu parceiro. Diante disso, desembarcou da viatura e ao abordar o réu encontrou maconha dentro de um porta-óculos, não se lembrando se havia cocaína também, dizendo ele se destinar ao consumo próprio. Ao ser informado de que seria conduzido à delegacia, o réu exaltou-se e resistiu com violência à sua detenção, sendo necessário o uso de força para contê-lo e algemá-lo, tendo sofrido lesões corporais, não se lembrando contudo em que parte do corpo. Dirigiram-se ainda ao pronto-socorro, onde o réu continuou agressivo e desferiu um chute em seu parceiro Rogério, não se recordando todavia se provocou lesões. Disse que o réu afirmou já ter feito coisas parecidas outras vezes, principalmente no centro, dizendo-se contra a polícia e o Estado, proferindo ainda alguns palavrões, não lembrando contudo quais especificamente, afirmando que estava sem dormir, parecendo encontrar-se sob o efeito de álcool, pois exalava odor etílico. Informou não conhecer o réu antes dos fatos, tendo o outro indivíduo permanecido tranquilo durante toda a abordagem. A vítima Rogério dos Santos Lima, policial militar, disse que no dia dos fatos estava a bordo de uma viatura, quando

avistou o réu e outro indivíduo caminhando pela calçada, tendo o réu mostrado o dedo médio na sua direção e de seu parceiro e os xingado, não se recordando contudo do que especificamente. Diante disso, desembarcou da viatura e ao revistar o réu encontrou maconha dentro de um porta-óculos, não se lembrando se havia cocaína também, dizendo ele ser para consumo próprio. Ao ser informado de que seria conduzido à delegacia, o réu exaltou-se e resistiu com violência à sua detenção, sendo necessário o uso de força para contê-lo e algemá-lo, tendo seu parceiro Sideam machucado o braço, encontrando-se o réu transtornado, parecendo sob o efeito de droga e/ou álcool. Foram até o pronto-socorro, onde o réu lhe desferiu chutes, acertando-o, não provocando lesões corporais contudo. Informou que o réu disse já ter participado de ações do grupo "black bloc", dizendo-se contra o Estado e a polícia. Informou que o outro rapaz colaborou com a equipe e até tentou acalmar o réu, não o conhecendo antes dos fatos, não sabendo dizer se ele possuía algum distúrbio psicológico, não se encontrando contudo em estado normal. A testemunha Dario Alexandre da Silva Souza, amigo do réu, disse que no dia dos fatos estavam caminhando juntos pela calçada, quando se aproximou uma viatura, sendo que os policiais ficaram encarando o réu, que abriu os braços e perguntou "o que foi?", sendo ele então abordado, tendo realmente resistido porque não queria ser algemado e nem colocado dentro do camburão. Informou que os policiais derrubaram o réu no chão e quebraram os óculos dele, sendo ambos conduzidos à delegacia, tendo ido conversar com o delegado, enquanto os policiais ficaram com o réu, que foi levado para realizar exame de corpo de delito, sendo que quando voltou estava todo machucado, dizendo os policiais que o réu lhes tentou agredir, contudo estavam dando risada. Informou não ter visto o réu mostrar o dedo do meio aos policiais, não tendo os xingado de "filhos da puta", tendo ele ficado bravo quando começou a ser agredido pelos policiais, já na delegacia. Disse que foram encontrados vestígios de cocaína e maconha com o réu, não tendo dito na delegacia o que constou no termo de depoimento que assinou a fls. 17, chegando a falar para o delegado que não concordava com o que estava escrito, mas como já era tarde e estava há muito tempo na delegacia, assinou para ir embora. Informou que o réu tinha consumido cocaína antes dos fatos, encontrando-se meio descontrolado por causa da droga, tendo ainda ingerido bebida alcoólica, estando ambos voltando de uma festa. O réu, em seu interrogatório na esfera policial, disse que realmente mostrou o dedo médio da mão aos policiais com a intenção de desacatá-los porque odeia policiais, que são racistas, negando contudo tê-los xingado ou haver resistido à prisão, tendo os policiais na verdade sido violentos. Confessou a posse de maconha e cocaína, destinadas ao consumo próprio, estando sob o efeito de drogas naquele momento, não sabendo indicar o local onde as adquiriu e nem de quem, tendo também chutado um policial dentro do pronto-socorro, pois o mesmo lhe empurrou (fls. 15). Em Juízo, disse que tem apenas alguns "flashs" de lembrança do ocorrido, pois estava muito bêbado e tinha usado droga. Informou que estava caminhando pela rua, quando policiais passaram lhe encarando, tendo aberto os braços e perguntado "o que foi?", sentindo um olhar de julgamento vindo deles, que tentaram prendê-lo, tendo realmente resistido, pois não queria ser algemado. Disse que os policiais foram bruscos durante a abordagem, tendo um deles lhe enforcado por trás, enquanto o outro lhe deu uma rasteira, caindo no chão e quebrando seus óculos, sendo que quando já estava caído, um deles colocou os joelhos no seu pescoço, achando que fosse morrer. Foi colocado no camburão e não lembra de mais quase nada, sendo levado ao posto de saúde para ser atendido, onde o policial continuou lhe machucando, tendo por isso dado um chute nele. Negou haver xingado os policiais, não tendo mostrado o dedo médio para eles, sendo apreendidas cocaína e maconha em seu poder, destinadas ao consumo próprio. Assim, verifica-se que o réu realmente cometeu todos os delitos descritos na denúncia, pois no dia dos fatos caminhava pela calçada juntamente com Dario Alexandre da Silva Souza e ao ver a aproximação de uma viatura mostrou o dedo médio na direção dos policiais Sideam e Rogério e os xingou, desacatando-os. Diante disso, foi feita a abordagem e na revista pessoal foram encontradas dentro de um porta-óculos 1,2 g de maconha e 0,1 g de cocaína, destinadas ao consumo próprio. Ao ser informado de que seria conduzido à delegacia, o réu exaltou-se e opôs-se à execução de tal ato mediante violência física,

desferindo chutes e socos nos policiais, provocando lesões corporais de natureza leve em Sideam, de acordo com o laudo de exame de corpo de delito de fls. 42. O réu e Sideam foram levados ao pronto-socorro, onde o réu praticou vias

de fato contra Rogério, desferindo-lhe chutes, sem contudo provocar lesões corporais. O depoimento da testemunha de defesa Dario, com a devida vênia, deve ser recebido com reservas, por ser amigo do réu, tendo natural interesse em vê-lo absolvido das acusações que lhe foram dirigidas, sendo estranho ademais que tenha lido o termo de depoimento que lhe foi apresentado na delegacia, discordado de seu conteúdo, dito isso ao delegado, e ainda assim o assinado. O fato, outrossim, de estar o réu eventualmente sob o efeito de bebida alcoólica e drogas não o beneficia, sendo de se invocar o disposto no art. 28, inciso II, do Código Penal, que é claro ao dispor que a embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade penal (RT 757/537, 564/389, 811/684, RF 272/306, RJDTACr 27/76), o mesmo se aplicando à pessoa que consome drogas e tem seu comportamento alterado em razão disso. Especificamente quanto ao desacato, tal crime não exige ânimo calmo, pelo que o estado de exaltação ou cólera não exclui o seu elemento subjetivo do tipo. Nesse sentido, RT 505/351, 417/285, 401/289, 304/478, 327/397 e 388/275, JTACrimSP 44/352 e 22/244. No mesmo sentido: "Desacato. Caracterização. Desrespeito a policiais militares no exercício da função. Ânimo colérico dos agentes. Irrelevância à caracterização do delito. Recurso conhecido e improvido" (TJMG, Ap. Crim. 1.070.401.002979-8/001, Rel. Des. Paulo César Dias, j. 22/02/2005).

"Desacato. Prova escorreita da autoria, confirmada pela confissão espontânea. Ânimo exaltado do agente não exime de responsabilidade, revelando-se típico da prática delituosa em questão. Redução da pena pecuniária" (TACrimRS, Ap. Crim. 297024077, 2ª Câ. Crim., Rel. Tupinambá Pinto de Azevedo, j. 30/10/2007). De outra parte, a materialidade do crime de posse de droga para consumo próprio está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 55/57, que apresentou resultados positivos para maconha e cocaína e contém a necessária fundamentação. A conduta do réu, neste aspecto, tipifica o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Não há que se falar em atipicidade da conduta do réu pelo só fato de ter sido surpreendido com pequena quantidade de drogas, destinadas ao consumo próprio, uma vez que o legislador não faz essa distinção, servindo o volume dela apenas para caracterizar, eventualmente, o crime de tráfico, bem mais grave. Por outro lado, enquanto não houver reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade da previsão contida no art. 28 da Lei nº 11.343/06, a mesma continua sendo criminosa. Por fim, não há que se falar em imputabilidade do réu, por não ter sido instaurado incidente de insanidade mental do mesmo, até por falta de pedido da defesa, não tendo este Juízo ademais vislumbrado nenhum distúrbio no mesmo, que comportou-se com absoluta normalidade em audiência. Passo ao cálculo das penas. Art. 28 da Lei nº 11.343/06: Atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do fato e a confissão do agente, aplico-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no art. 28, inc. I, da Lei nº 11.343/06. Art. 129, caput, do Código Penal: Novamente atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, fixo a base no mínimo legal, ou seja, 3 meses de detenção, em regime aberto. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes em relação a este crime, nem causas de aumento ou diminuição. Art. 329 do Código Penal: Pelas mesmas razões, fixo a base no mínimo legal, ou seja, 2 meses de detenção, em regime aberto. Prejudicada a atenuante da confissão em relação a este crime, por ter a pena sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Não há circunstâncias agravantes, nem causas de aumento ou diminuição. Art. 331 do Código Penal: Por idênticas razões, faço opção pela pena de multa, prevista alternativamente, a qual reputo suficiente para a punição por esta conduta, também de menor gravidade, fixada no mínimo de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo em vigor na época dos fatos. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes em relação a este crime, nem causas de aumento ou diminuição. Art. 21 do Decreto-lei 3688/41: Por idênticas razões, faço novamente opção pela pena de multa, prevista alternativamente, a qual igualmente reputo suficiente para a punição por esta conduta, também de menor gravidade, fixada no mínimo de 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo em vigor na época dos fatos. Prejudicada a

atenuante da confissão em relação a esta contravenção, por ter a pena sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Não há circunstâncias agravantes, nem causas de aumento ou diminuição. Considerando que os crimes e a contravenção foram praticados em concurso material entre si, as penas deverão ser cumuladas, totalizando assim 5 meses de detenção, em regime aberto, 20 dias-multa e advertência sobre os efeitos das drogas. Tendo em vista que as penas privativas de liberdade não excedem 6 meses, cabível a substituição por multa, fixada em 20 dias-multa, no mesmo valor unitário, nos termos do art. 60, § 2º, do Código Penal. Isto posto, julgo procedente a ação penal movida contra VINÍCIUS MARQUES DOS SANTOS MALGUEIRO, qualificado nos autos, e CONDENO-O, como incurso nos arts. 28 da Lei nº 11.343/06, 129, caput, 329 e 331, todos do Código Penal, e 21 do Decreto-lei nº 3.688/41, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de advertência sobre os efeitos das drogas e 40 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo em vigor na época dos fatos, com correção monetária desde então. Audiência de advertência após o trânsito em julgado. Oportunamente, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados. Dada e publicada em audiência, saem os presentes intimados desta sentença. Cumpra-se". Nada mais. Encerrou-se o presente termo que depois de lido, vai devidamente assinado. Eu, _____ (Josiel Silveira Rosa), escrevente, digitei e subscrevi.

DR. PROMOTOR:

DR. DEFENSOR DO RÉU:

RÉU: _____